

0005118-47.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA (ou Marcos Vinicius Lopes)

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

MARCOS VINICIUS FERREIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

0005118-47.2021.8.26.0510 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005118-47.2021.8.26.0510 - 2021/000605

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA (ou Marcos Vinicius Lopes)

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 07 de setembro de 2021, por volta das 23:20 horas, na rua Cordeirópolis, com a Avenida Campinas, Jardim Paulista, no município de Santa Gertrudes, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 39 (trinta e nove) invólucros contendo a substância entorpecente denominada cocaína, na forma de crack, totalizando peso líquido de 11,4 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11 e laudo de constatação de fls. 13/15, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 07 de fevereiro de 2022. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, com posterior interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, devendo ser majorada em decorrência da recidiva, com o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com fixação de regime prisional inicial fechado, e imposição da pena de perdimento em relação aos valores apreendidos.

Já a ilustre Defensora Pública sustentou insuficiente a prova produzida, pelas razões que cuidou em expor, pugnando pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Assim não se entendendo, requereu a desclassificação do delito atribuído inicialmente ao acusado para a infração prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos. Em caso de condenação pela imputação inicial, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, já que não específica a recidiva, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional inicial aberto, inclusive por força do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, promovendo-se a restituição dos valores apreendidos e facultando-se a interposição de recurso em liberdade.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque trazia consigo, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 168/171, com resultado positivo para cocaína.

Controverte-se sobre a posse da totalidade do entorpecente apreendido e sua destinação mercantil.

Ouvido em Juízo, o acusado admitiu que na ocasião dos fatos estava no local indicado na denúncia, reconhecido ponto de compra e venda de entorpecentes, quando acabou por empreender fuga com a aproximação de uma guarnição, mas em função da presença igualmente no local de indivíduo que o teria atingido anteriormente com uma faca. Posteriormente, ainda segundo o exposto, acabou abordado, apreendendo-se em seu poder nove porções de crack, que disse destinadas ao próprio uso, além da quantia de dez reais. Acrescentou que o restante do entorpecente exibido à d. Autoridade Policial pelos Policiais Militares que o abordaram não lhe pertenciam, como também não o restante da quantia em dinheiro apreendida, observando que se encontrava em liberdade provisória, que lhe foi concedida por conta de prisão em flagrante que também disse "forjada" pela prática de igual delito.

Todavia, a versão deduzida pelo acusado não contou com nenhum apoio probatório e ainda foi contrariada pela prova produzida.

De fato, os Policiais Militares ouvidos em juízo, reiterando o que exposto contemporaneamente aos fatos, afirmaram que na ocasião estavam em patrulhamento pelo local, na vizinha localidade de Santa Gertrudes, já conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, quando avistaram o acusado, igualmente já conhecido por envolvimento nesta prática delitiva, o qual imediatamente empreendeu fuga. Acrescentaram os Policiais Militares que encetaram acompanhamento, tendo o acusado percorrido aproximadamente quatro quarteirões, na fuga inclusive atravessando uma rodovia, notando-se quando ele jogou no interior das dependências de uma escola um invólucro, sendo em seguida abordado. Com ele apreenderam-se nove porções de crack, embaladas em uma fieira, além da quantia de duzentos e sessenta e cinco reais. Em seguida, retornaram ao mencionado estabelecimento de ensino, onde encontraram, no local onde ele arremessara anteriormente um invólucro, outras trinta porções de crack, embaladas da mesma forma, admitindo então o acusado que estava realizando o comércio ilícito e que a quantia apreendida decorria da prática delitiva. Como se tem sempre consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais militares envolvidos nas diligências. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu). Deste modo, para além da idoneidade de que gozam os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na apreensão de entorpecentes, evidenciou-se que o acusado se encontrava em local já conhecido como ponto de tráfico, sendo ele também já conhecido por esta prática delitiva, tendo empreendido fuga, quando avistou a guarnição policial, até que acabou abordado, apreendendo-se em poder dele várias porções de crack, não sem antes ter dispensado um invólucro contendo outras tantas (trinta) porções da mesma substância entorpecente, circunstâncias que inequivocamente possibilitam seguro juízo de convicção sobre a posse a destinação mercantil da droga apreendida, configurando o delito a ele irrogado.

Por fim, considerando que os valores apreendidos estavam junto com as porções de entorpecente dispensadas pelo acusado, igualmente possível concluir que decorriam da atividade ilícita, a fazer incidir a pena de perdimento.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, não se tratando de quantidade expressiva de entorpecentes, possível seja a pena-base fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

A pena-base, no entanto, deve ser agravada em 1/6 (um sexto) em função da recidiva (fls. 85), não se exigindo que seja específica, totalizando 5 (cinco) anos e 10

(dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado. Por fim, diante do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, a recidiva também afasta objetivamente a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", Lei nº 11.343/06 e artigo 61, inciso I, do Código Penal, CONDENO o acusado MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do acusado, corrigido desde a época do fato, operando-se ainda o perdimento da quantia apreendida em favor da União, porque decorrente da ação ilícita, nos termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, deve ser considerada a reincidência, como também a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispõe o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, promanada do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênia, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênia, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interditada a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descuidar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras.

Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses

(cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, não apenas em função da natureza hedionda do delito, mas também em função da recidiva, inviabilizando-se a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória.

A propósito: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1).

E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inoccorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008).

E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

Por fim, diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA